

【基本案情】

朱某某与李某某系二婚夫妻，双方于2012年11月结婚，婚后未生育子女。李某某与其前妻育有一子李某。案涉房屋系李某某单位分配的房改房，于2011年10月登记在李某某名下。朱某某和李某某婚后居住在案涉房屋中。李某某于双方结婚的次日自书《协议》，其上载明：案涉房屋产权归儿子李某所有；如果男方先去世，女方可以继续居住到百年，李某对女方多加照顾。协议下方有李某某签名及按捺手印和朱某某签名。2022年4月，李某某去世。

在案由为遗嘱继承纠纷的另案中，法院于2023年6月判决案涉房屋归李某所有。

朱某某在本案中请求其对案涉房屋享有居住权。李某辩称：李某某在遗嘱中设立的居住权并未进行登记，故并未生效。李某同时以其名下并无其他房屋为由提出反诉：请求判令李某对案涉房屋享有居住权。

【案件焦点】

1. 李某某在遗嘱中为朱某某设立的居住权是否生效；2. 法院是否应为名下无房的李某在案涉房屋设立居住权。

【法院裁判要旨】

北京市丰台区人民法院经审理认为：以遗嘱方式可以设立居住权。关于案涉《协议》的性质，生效判决已认定为李某某的自书遗嘱，该遗嘱具有法律效力。根据该遗嘱，案涉房屋已另案判决由李某继承所有。关于遗嘱中朱某某可以就案涉房屋居住到百年的意思表示真实、明确，故朱某某享有案涉房屋的居住权。关于李某提出的案涉房屋居住权未登记的抗辩意见，现北京房屋居住权登记工作尚未正式启动，在遗嘱有效的前提下，朱某某的居住权不因未登记而丧失。故，对李某的抗辩意见不予采纳。对于李某主张的要求确认其对案涉房屋享有居住权等反诉请求，缺乏事实及法律依据，不予支持。

北京市丰台区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第三百六十六条、第三百七十一条规定，判决：

一、确认朱某某对案涉房屋拥有居住权；

二、驳回李某的反诉请求。

李某不服一审判决，提起上诉。

北京市第二中级人民法院经审理认为：因朱某某所享有居住权是依据李某某的遗嘱而非基于协议，一审法院依据北京市居住权登记的客观情况，对李某主张居住权未登记而丧失的抗辩意见未予采信，并无不当。因朱某某对案涉房屋享有居住权，李某对案涉房屋的所有权的部分权能必然受到限制。一审法院依据案涉房屋的实际居住情况、朱某某本人意愿，对李某提出的反诉请求未予支持，符合本案客观实际。

北京市第二中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决：

驳回上诉、维持原判。

【法官后语】

关于居住权的设立，《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定了合同和遗嘱两种方式。通过合同设立居住权的，《民法典》设有五个法律条文，规范得具体而完备。而通过遗嘱设立居住权，则表述为参照适用合同设立居住权的有关规定。运用“参照”的法律适用方法，说明立法者充分考虑

了以遗嘱方式设立居住权区别于以合同方式设立居住权的特殊性，即遗嘱是《民法典》继承编的调整对象，对于遗嘱的形式和实质要件的审查，首先应当适用继承编的相关规定，因继承编没有规定遗嘱设立居住权的问题，所以遗嘱设立居住权的效力审查，应当根据遗嘱的订立方式、特点变通适用合同设立居住权的有关规定。因此，在审查是否以遗嘱方式设立居住权时，既要考虑到参照前后之对象的相似点，也要考虑到参照前后之对象的差异点^①。本案从目前关于居住权设立、登记的实际情况出发，旨在探究以遗嘱方式设立居住权的生效要件。

^①雷槟硕：《“应当参照”：适度变通的类案同判义务》，载《社会科学》2024年第3期。

一、可设立居住权的遗嘱形式

《民法典》规定了六种遗嘱形式，分别为自书遗嘱、代书遗嘱、打印遗嘱、录音录像遗嘱、口头遗嘱和公证遗嘱。在通过合同方式订立居住权的框架下，《民法典》规定当事人应当采用书面形式。而在通过遗嘱方式设立居住权的情况下，自书遗嘱、代书遗嘱、打印遗嘱、公证遗嘱显然符合“书面形式”的要求，而非传统意义“书面形式”的录音录像遗嘱和口头遗嘱能否设立居住权就是一个值得商榷的问题。

就录音录像遗嘱来说，虽然并非传统意义上的写在纸面上的遗嘱，但是根据《民法典》第四百六十九条第三款规定，以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。因此，录音录像遗嘱可以视为广义上的“书面形式”，也即可以通过录音录像遗嘱来设立居住权。

就口头遗嘱来说，其显然不符合“书面形式”的要求，故一直有不能以口头遗嘱设立居住权的说法。此种观点显然是将遗嘱设立居住权融进了合同设立居住权的法律框架之中，而忽略了《民法典》第三百七十一条“参照适用”的规定。

首先，《民法典》规定的口头遗嘱的生效要件较为严格，即在危急情况下且需要有两名以上见证人在场见证，以此保证遗嘱内容符合立遗嘱人的真实意愿。因此，对于口头遗嘱，两位见证人的证人证言能够达到同书面形式一样的证明效果。

其次，最高人民法院的相关观点认为，对于未采用书面形式的设立居住权的合同，倾向于给予补救措施^①。举重以明轻，对难以采用书面形式的口头遗嘱，更应予以宽容对待。

最后，法律不应强人所难。若严苛地认为于危急情况下立遗嘱人必须采用

^①最高人民法院民法典贯彻实施工作领导小组：《中华人民共和国民法典物权编理解与适用（下）》，人民法院出版社2020年版，第868页。书中认为：“未采用书面形式的居住权合同，原则上不发生效力。但是，如果仅仅为强调签订合同的谨慎和追求诉讼的便利，就对欠缺形式要件的合同一律评价为未成立或者无效，那么对当事人交易的积极性、交易安全和效率无异于重大打击，反而是舍本逐末。因此，欠缺形式要件的合同仍应设计补救措施。”

书面形式设立居住权，则剥夺了部分立遗嘱人处分自己名下财产的自由，限制了部分弱势群体取得居住权的正当权益，而这些显然与《民法典》设立居住权的初衷背道而驰。

二、通过遗嘱方式设立居住权是否以登记为生效要件

居住权系一项用益物权，具有对世性。《民法典》第三百六十八条亦明确规定，通过合同设立居住权的，应当向登记机构申请居住权登记。居住权自登记时设立。故，通过遗嘱设立居住权的案件中，一方当事人常以该居住权未经登记不发生法律效力进行抗辩。

然而，合同和遗嘱作为设立居住权的两种方式，具有各自的特点，在遗嘱设立居住权的框架下，对于合同设立居住权的相关规范，仅是参照，并非严格适用。首先，从取得居住权的合法性来看，遗嘱系立遗嘱人生前真实的意思表示，应予尊重。且存在立遗嘱人立遗嘱时处于危急状态的特殊情况，此种情况下苛求立遗嘱人进行登记，未做强人所难。其次，从权利救济途径来看，若严格要求居住权经过登记才能生效，则可能存在房屋所有权继承人在办理居住权登记之前将房屋出售的情形，此种情况下居住权人最基本的居住利益将难以得到保障。此种观点与最高人民法院的相关观点一致，即以遗嘱设立居住权的，不适用《民法典》第三百六十八条“居住权自登记时设立”的规定^①。

三、法院以裁判为弱势群体设立居住权的利益衡量

《民法典》第一千一百四十一条对于在遗嘱中为弱势群体保留必要的遗产份额进行了规定^②。该条款又称“必留份”条款，是为了保障每一位继承人都能够得到最基本的生活保障，不因被继承人的死亡而导致生活难以为继。但该条款的适用主体又有严格的限制，即缺乏劳动能力又没有生活来源的继承人。此种严格的限制，体现了法律希望给年老体弱的弱势群体生活予以最基本的保

^①最高人民法院民法典贯彻实施工作领导小组主编：《中华人民共和国民法典物权编理解与适用（下）》，人民法院出版社2020年版，第899页。

^②《民法典》第一千一百四十一条规定，遗嘱应当为缺乏劳动能力又没有生活来源的继承人保留必要的遗产份额。

障，同时含有鼓励有劳动能力者自食其力的价值取向。

当“必留份”条款碰到“居住权”这一新制度，对该条款可诠释出新的解读。我国需要居住权制度来为“居无定所”的特定群体提供基本的生活保障，从而满足其“居者有其屋”的现实需求^①。住房需求是人类最基本的需求之一，